

1501487-33.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... por sua vez, em relação ao delito de tráfico de drogas, pediu a absolvição do acusado, em face de insuficiência de provas, aplicando-se o princípio "in dubio pro reo". Subsidiariamente, requereu seja desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06, e, em caso de condenação por tráfico, a aplicação da pena no mínimo legal. Quanto ao crime de lesão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501487-33.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501487-33.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290322/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 21005677 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2290322 - DEL.DEF.MUL. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUBENS ALVES E SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1501487-33.2021.8.26.0603 (controle nº 2141/2021)

Vistos.

RUBENS ALVES E SILVA, vulgo "Rubão", qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

e artigo 129, § 9º, do Código Penal, observando-se o teor da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 21h00, à Rua Jerônimo Sabotto, 651, bairro Quemil, nesta cidade e Comarca de Birigui, guardava e mantinha em depósito no interior de uma residência abandonada, com o fim de tráfico, 135,49 gramas de maconha, fracionados em 22 porções, 33,15 gramas de cocaína, fracionados em 47 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 07/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudos de constatação prévia de fls. 15/16 e laudo de exame toxicológico de fls. 92/96.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo acima descritas, na Rua Jerônimo Sabotto, 459, Quemil, nesta cidade e comarca de Birigui, em concurso material de crimes, RUBENS ALVES E SILVA, vulgo "Rubão", ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Elídia Fernanda André Borges, produzindo nela as lesões corporais leves descritas no laudo pericial de fls. 80/81.

Recebida a denúncia em 16 de novembro de 2021 (fls. 107/108), o acusado foi regularmente citado (fl. 125), apresentando defesa escrita a fls. 131/138.

Na instrução, foram colhidas as declarações da vítima e tomados os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas em comum, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do acusado (fls. 202/203).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 207/212).

A defesa, por sua vez, em relação ao delito de tráfico de drogas, pediu a absolvição do acusado, em face de insuficiência de provas, aplicando-se o princípio "in dubio pro reo". Subsidiariamente, requereu seja desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06, e, em caso de condenação por tráfico, a aplicação da pena no mínimo legal. Quanto ao crime de lesão corporal, requereu seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (fls. 215/222).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública que se destina a apurar a prática de condutas que, em tese, estariam a caracterizar os delitos de lesão corporal dolosa, em cenário de violência doméstica (artigo 129, § 9º do Código Penal), e de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06).

A ação penal é totalmente procedente.

Ao término da instrução criminal, e após uma atenta análise das provas reunidas nos autos, não se pode deixar de reconhecer que a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Considerando que a presente ação penal apura dois delitos, passo a analisá-los separadamente.

Tráfico de drogas.

Quanto a esse delito, a ação é procedente, porque a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01); recibo de entrega de preso (fls. 02/03); o boletim de ocorrência (fls. 07/12); auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); nota de culpa (fl. 19); laudos periciais (fls. 88/91, 92/93 e 94/95); relatório policial (fls. 97/99); depoimentos das testemunhas e as indigestas negativas apresentadas pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

Tanto na delegacia, quanto em juízo, o acusado negou a prática do tráfico, dizendo que agrediu sua ex-companheira e logo após, uma viatura da polícia militar apareceu na residência abandonada em que estava. Franqueou a entrada dos policiais e informou que havia porções de maconha e cocaína na residência, que seriam para seu uso, e vários eppendorfs vazios (fls. 05/06 e 202/203).

Contudo, a negativa do acusado está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Com efeito, as testemunhas Igor Ilan Argentato e Marcos Vinicius Aragão de Almeida, policiais militares, ouvidas nas fases policial e judicial, relataram que foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, o indivíduo já havia se evadido, tendo a vítima informado as características e a direção que foi o acusado. Avistaram o suspeito em uma residência abandonada e, ao perceber a viatura entrou, fechou o imóvel e dispensou alguns objetos pela janela. Indagado sobre o que havia dispensado, o acusado admitiu que seriam alguns pinos de cocaína e porções de maconha. Localizaram 22 porções de maconha e 20 eppendorfs com cocaína e, dentro da casa, foram localizados centenas de eppendorfs vazios, mais 27 eppendorfs com cocaína. O acusado disse que seria para seu consumo. O local onde foram encontrados os entorpecentes é conhecido como ponto de venda de drogas (fls. 02/03, 04 e 202/203).

Como se viu, os policiais confirmaram que viram o réu dispensando as drogas ao avistar a viatura, bem como que o acusado confirmou a propriedade dos entorpecentes, e que o local é conhecido ponto de venda de drogas.

Os relatos dos policiais, no caso concreto e levando em conta os demais elementos de prova existentes nestes autos, evidenciam, com segurança, que o réu incidiu na prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicarem o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque não apontaram nada que justificasse essa circunstância.

A vítima das agressões, Elidia Fernanda André Borges, ouvida em juízo, disse que o acusado lhe agrediu e não soube dizer nada sobre os fatos do tráfico de drogas (fls. 202/203).

Quanto aos entorpecentes apreendidos, a perícia apontou que consistem realmente em "maconha" e "cocaína" (exame químico-toxicológico de fls. 92/93 e 94/95).

Assim, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, ou seja, 135,49 gramas de maconha e 33,15 gramas de cocaína; as circunstâncias da abordagem do réu (dispensou as drogas ao avistar a viatura e foi abordado em local conhecido pelo comércio de drogas); a forma de acondicionamento das drogas, prontas para o comércio; e a apreensão de centenas de eppendorfs vazios e celular, estão a caracterizar a traficância.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente guarde ou mantenha em depósito para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Lembre-se que o réu foi denunciado por guardar e manter em depósito drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado guardava e mantinha em depósito 135,49 gramas de maconha e 33,15 gramas de cocaína, substâncias essas entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora o acusado tenha alegado que era usuário de droga e que o entorpecente apreendido era para seu consumo, tais alegações não restaram comprovadas, pelo contrário, foram afastadas pela prova colhida durante a instrução, que confirmou a prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Ademais, a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental que demonstrassem sua alegação.

Por outro lado, ainda que se admitisse o acusado como usuário, esse fato, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas: se o réu é usuário há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário de droga não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

Portanto, não há que se falar em desclassificação do crime imputado para o de uso de drogas previsto no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito.

Lesão Corporal.

Neste ponto, a ação também é procedente.

A autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01); recibo de entrega de preso (fls. 02/03); o boletim de ocorrência (fls. 07/12); o laudo de exame de corpo de delito (fls. 80/81); o relatório policial (fls. 97/99); as declarações da vítima; os depoimentos das testemunhas e confissão apresentada pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

O acusado, na delegacia e em juízo, disse que foi até a casa de sua ex-companheira e viu que ela havia saído de casa com uma outra pessoa. Assim que a vítima retornou, o acusado foi em sua direção e desferiu dois socos em sua cabeça e um chute em sua perna (fls. 05/06 e 202/203).

A confissão livre e espontânea prestada no processo serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, a confissão do réu encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, a vítima Elidia Fernanda André Borges, ouvida em juízo, disse que o acusado lhe agrediu com socos, chutes e bateu em sua cabeça com um objeto que não conseguiu ver (fls. 202/203).

Como se viu, a vítima confirmou que foi agredida pelo acusado.

Não se pode olvidar que, em caso como o dos autos (delitos praticados no âmbito de violência doméstica), a palavra da vítima, confirmada por testemunhas e também pelo acusado, é de excepcional importância e merece credibilidade quando harmônica em ambas as fases da persecução penal.

As testemunhas Igor Ilan Argentato e Marcos Vinicius Aragão de Almeida, policiais militares, ouvidas nas fases policial e judicial, relataram que foram acionados para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima informou que seu ex-companheiro foi até sua residência e desferiu dois golpes em sua cabeça com um objeto e se evadiu. O acusado foi localizado e admitiu que havia ido até a residência de sua ex-companheira e desferido dois golpes em sua cabeça com o celular (fls. 02/03, 04 e 202/203).

Reitero, aqui, os argumentos acima expostos sobre o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais.

O laudo de exame de corpo de delito de fls. 80/81 demonstrou que o réu ofendeu a

integridade corporal da vítima, provocando-lhe lesões corporais leves. Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descritos na denúncia, o réu ofendeu a integridade corporal da vítima Elidia Fernanda André Borges, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade.

Reconheço a ocorrência do crime e passo à aplicação das penas, separadamente.

Lesão Corporal.

O réu ostenta maus antecedentes (fl. 224 – processo nº 0000329-32.2011.8.26.0097 e fl. 226 – processo nº 0202635-16.2007.8.26.0651), razão pela qual uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 não lhe é favorável, ensejando a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 223 – processo nº 0000785-06.2016.8.26.0097), no entanto, compenso-a com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena fixada no parágrafo anterior.

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar apelação interposta em ação penal que tramitou por este Juízo, decidiu sobre o acerto da referida compensação e a manteve, conforme parte voto que segue:

“... Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls. 59/69) e a atenuante da confissão foram compensadas, de modo que as reprimendas permaneceram nos patamares iniciais de quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa” (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.282738-3, Comarca de Birigui, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 25.02.2010, v.u.).

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Torno definitiva a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Tráfico de drogas.

O acusado ostenta maus antecedentes (fl. 224 – processo nº 0000329-32.2011.8.26.0097 e fl. 226 – processo nº 0202635-16.2007.8.26.0651), razão pela qual uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhe é favorável, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Afora isso, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução da considerável quantidade de droga no mercado (nada menos do que 135,49 gramas de maconha e 33,15 gramas de cocaína), se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima, tratando-o igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes.

Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das conseqüências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e conseqüências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repressão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro - JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em conseqüência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS - AC - 687055624 - Rel. Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154).

PENA - Agravantes - Tráfico de entorpecentes - Associação - Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o “modus operandi” do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível “reformatio in pejus”, a pena cominada na r. sentença deve prevalecer - Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 23.8.2007 - V.U. - Voto n. 6.277)

Portanto, levando em conta o dado elencado, nos aspectos acima relatados (maus antecedentes e quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 223 - processo nº 0000785-06.2016.8.26.0097), razão pela qual elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes a ser consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Não é caso de incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que afasta o benefício.

Ademais, ainda que assim não fosse, restou demonstrado, por todos os elementos acima descritos, bem como pela apreensão de grande quantidade de drogas, de espécies diversas (nada menos do que 135,49 gramas de maconha e 33,15 gramas de cocaína), que o acusado se dedicava à narcotraficância em escala expressiva, guardando grande quantidade de droga, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida.

Neste sentido, já se decidiu:

“ Sem incidência , porém, na última fase da dosagem, de retroativa redutora, por conta do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que, pese a primariedade e bons antecedentes, concretamente, a forma de embalagem da droga apreendida (cerca de sessenta e cinco invólucros), sua natureza (crack) e forma de ação desenvolvida - para fim de venda a indeterminado número de pessoas - antes de caracterizar eventual pequeno tráfico, traz indicações de fazer do fato modo de vida, exercício de atividade criminosa.”

Em outros termos, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar conseqüências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte do acusado, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do

pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, razão pela qual não faz jus à redução em questão.

Torno definitiva a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Observa-se, pois, que, diante dos diferenciados tipos de pena privativa de liberdade (reclusão e detenção), não poderá ser aplicado o concurso material, com a soma das penas. Fixo, assim, cada pena separadamente, observando-se, na fase de execução, o disposto no artigo 69, caput, 2ª parte, do Código Penal.

No que toca ao delito de lesão corporal, o regime inicial será o semiaberto, mesmo levando em conta a detração penal, haja vista que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para:

1) CONDENAR RUBENS ALVES E SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, dando-o como incurso na pena do artigo 129, § 9º, do Código Penal;

2) CONDENAR RUBENS ALVES E SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 24/10/2021 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

No tocante ao crime de tráfico de drogas, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal

Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso. Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS – mencionado nas razões recursais –, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente – até as pedras estão cansadas de saber –, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que – até o momento – jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de

direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput – e não um crime autônomo –, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372). Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem todos os argumentos expostos nos votos supracitados, no caso concreto, a substituição não é possível porque o acusado ostenta maus antecedentes, é reincidente e a pena aplicada é superior a quatro anos. Ademais, o réu é reincidente específico, o que afasta até mesmo a aplicação do § 3º do artigo 44 do Código Penal. Afora isso, o réu estava guardando considerável quantidade de entorpecente para entrega a consumo de terceiros, o que demonstra que o benefício não seria recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime praticado.

Quanto ao delito de lesão corporal, ausentes os requisitos legais, deixo de substituir a pena corporal por restritiva de direitos, já que o artigo 44, inciso I, do Código Penal veda substituição na hipótese de crime cometido com violência e grave ameaça. De outra parte, a Lei Maria da Penha, em seu artigo 17, proibiu expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como as penas de fornecimento de cestas básicas ou outras de prestações pecuniárias.

Neste sentido, a Súmula 588 do Supremo Tribunal Federal:

"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

O acusado deverá continuar a responder preso a este processo, eis que sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme decisão proferida às fls. 55/57, a cujos fundamentos me reporto, como razão de decidir, bem como aqueles expostos na decisão de fls. 176/177, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos. Afora isso, o acusado estava cumprindo pena em regime aberto por outro processo de tráfico. Nesse aspecto, a ordem pública merece resguardo.

Por fim, anote-se que o réu tinha em depósito grande quantidade de droga, o que traria efeitos altamente lesivos à sociedade e só vem confirmar a necessidade de

manutenção de sua prisão cautelar, para garantia da ordem pública, lembrando que o acusado ostenta maus antecedentes e é reincidente em crime doloso.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada e realizada (fls. 142/143), nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Quanto aos objetos apreendidos a fls. 13/14 (ependorfs vazios e faca), embora sejam instrumentos do tráfico de drogas, o certo é que, diante da natureza dos objetos, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre a destruição dos objetos, instruindo-se o ofício com as cópias.

Por fim, em relação ao celular apreendido às fls. 13/14, diante da natureza do objeto, (e por ser, o celular, instrumento para a prática do tráfico de drogas), entendo não ser caso de perda para o SENAD, mas sim destruição, a qual fica desde já determinada, mas que deverá ser cumprida somente após o trânsito em julgado da presente.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA